

1502157-62.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Joice Sofiati Salgado

Comarca: Jardinópolis

Foro: Foro de Jardinópolis

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... para a caracterização do delito de tráfico, é suficiente que o agente traga consigo o entorpecente e os guarde- o que ficou sobejamente demonstrado nos autos -, pois a consumação não exige qualquer resultado, como a venda ou a entrega efetiva ao consumo.

Em casos tais já se decidiu:

"Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jardinópolis[Foro do Processo]

2ª Vara

Praça Doutor Mário Lins, s/nº, Jardinópolis - SP - cep 14680-000

1502157-62.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502157-62.2022.8.26.0530

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL FERNANDO PEREIRA APARECIDO

Vistos,

I. Relatório.

GABRIEL FERNANDO PEREIRA APARECIDO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, do Código Penal, porque, no dia, horário e local indicados na denúncia, nesta cidade e Comarca de Jardinópolis/SP, teria trazido consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 2,330g (dois gramas e trezentos e trinta miligramas) da substância entorpecente cocaína, acondicionados em 08 (oito) microtubos de plástico de tipo "eppendorf" de cor roxa; e 14,330g (quatorze gramas e trezentos e trinta miligramas) da substância entorpecente "Cannabis Sativa, L," popularmente conhecida como "maconha", acondicionados em 1 (um) invólucro de plástico incolor.

Notificado (fls.105), o acusado apresentou defesa preliminar (fls.98/100).

A denúncia foi recebida em 31 de outubro de 2022 (fls.106/107).

O acusado foi citado às fls.122.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns e, ao final, o réu foi interrogado.

Nas alegações finais, a representante do Ministério Público pleiteou a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia. A defesa requereu a improcedência da ação e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, além do reconhecimento dos benefícios legais.

É o relatório.

II. Fundamentação.

A pretensão punitiva estatal deve ser julgada procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.05), boletim de ocorrência (fls.10/12), auto de exibição e apreensão (fls.13/14), imagem fotográfica (fls.15), pelo laudo de exame químico toxicológico (fls.46/48), bem como pela prova oral produzida.

Passo a análise da autoria do crime.

O acusado, em fase extrajudicial, declarou que estava fumando "maconha" com seu amigo "PEDRINHA", quando a Polícia Militar chegou e o abordou. Negou ser proprietário dos entorpecentes apreendidos e disse que eram de propriedades de seu colega "PEDRINHA"; porém, os policiais não acreditaram e levaram apenas ele para a Delegacia de Polícia (fls.08). Em juízo, o réu, 18 anos, disse que não estava praticando o tráfico e que foi ao local comprar drogas para seu consumo próprio. Alegou que tinha pego o entorpecente (cocaína e maconha), mas não houve tempo de pagar porque os policiais chegaram. Disse que não tinha balança e não havia tal objeto no local. Narrou que trabalha coletando reciclagem com seu avô. Informou que fazia cerca de dois meses que tinha deixado a Fundação Casa.

O policial militar Rafael Eduardo Facioli, em fase extrajudicial, declarou que, juntamente com sua colega de farda, estavam em patrulhamento em local já conhecido pela traficância, quando avistaram dois indivíduos, sendo que o acusado estava manuseando alguma coisa. Asseverou que, quando chegaram próximos, constataram que o réu estava sentado e possuía entre as pernas uma balança de precisão e um saco com uma porção de "maconha". Aduziu que foi feita busca pessoal no acusado, sendo encontrado 08 (oito) porções de cocaína e o valor de R\$104,00 (cento e quatro reais), em notas diversas, em seus bolsos. Disse que, como o local era de grande movimentação de pessoas, não foi possível uma melhor abordagem do segundo indivíduo (fls.06). Em juízo, informou que estavam em patrulhamento em local conhecido pela traficância, onde avistaram o réu sentado, manuseando uma balança de precisão, oportunidade em que tentou se evadir. Disse que havia cocaína na posse do acusado, mas não se recordou a quantidade. Narrou que junto ao réu havia uma balança de precisão e dinheiro. Esclareceu que a droga estava nas vestes do réu. Disse que apenas conseguiu abordar ele, em virtude do tumulto que costuma ocorrer no local. Declarou que havia pessoa próxima a ele em pé, mas não conseguiram abordá-la. Não se recordou da justificativa ofertada pelo réu. Narrou que conhecia o acusado por estar em pontos de tráfico.

Em juízo, a policial militar Natana Aparecida Martins de Jesus corroborou o relatado por seu colega de equipe. Disse que avistaram dois indivíduos e o réu estava com objeto na mão. O outro indivíduo se evadiu. Realizada abordagem, constataram que o réu segurava uma balança de precisão, e, depois, foi encontrado entorpecente em suas vestes. Também foi encontrada droga em um saquinho, que estava

com o réu. Afirmou que conhecia o réu em virtude de avistá-lo em locais da região. Narrou que é uma região de prática de tráfico.

Eis o teor da prova oral.

Analisando-se a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, tem-se que o quadro probatório, de modo algum beneficia o acusado, não tendo sua versão sido comprovada, conforme ônus que competia à Defesa.

Com efeito, os depoimentos dos policiais foram firmes, coerentes e harmônicos no sentido de afirmarem que encontraram entorpecentes, balança de precisão e dinheiro em notas diversas na posse do acusado.

E, não há nos autos qualquer indício de que os policiais tenham agido de forma abusiva ou para consciente e injusto prejuízo do acusado. A propósito, não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais militares.

No caso, a quantidade e a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes apreendidas, embaladas individualmente (cocaína), junto da balança de precisão e de dinheiro sem comprovação de origem lícita, e o modo e local em que se deu a apreensão (conhecido pela prática do comércio espúrio) demonstram, à saciedade, que a droga se destinava ao consumo de terceiros.

Embora os policiais não tenham visto o réu entregando drogas a terceiros, tal fato não tem o condão de afastar sua responsabilidade criminal, vez que a figura típica capitulada no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 trata-se de um tipo misto alternativo e tem como núcleos (...) trazer consigo, guardar, (...), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". Assim, para a caracterização do delito de tráfico, é suficiente que o agente traga consigo o entorpecente e os guarde- o que ficou sobejamente demonstrado nos autos -, pois a consumação não exige qualquer resultado, como a venda ou a entrega efetiva ao consumo.

Em casos tais já se decidiu:

"Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga à terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercancia se destina o tóxico encontrado" (TJSP - Ap. 187.915-3/2 - Rel. CRISTIANO KUNT - RT 727/478).

Portanto, a condenação do acusado é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena.

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, verifica-se que se trata de réu que não ostenta maus antecedentes. Significativa, mas não tamanha a quantidade de drogas, de modo que se fixa a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo unitário, tendo em vista a ausência de elementos que demonstrem a real situação econômico-financeira do acusado.

Não há agravantes a serem consideradas. Presente a atenuante da menoridade relativa. Todavia, deixo de reduzir a reprimenda, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal e esta circunstância não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo previsto em lei, segundo dispõe a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Não há causas especiais de aumento e de redução de pena a serem apreciadas.

Nesse ponto, observa-se que o réu registra antecedentes de infrações equivalentes ao tráfico de drogas na Vara da Infância e Juventude (págs. 84/85, 86/87 e 88/89), tendo inclusive cumprido medida socioeducativa de internação por duas vezes, e deixado a Fundação Casa pouco tempo antes dos fatos, como ele próprio declarou quando interrogado judicialmente, o que denota dedicação à atividade criminosa, havendo evidente reiteração delitiva, o que veda a incidência da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“Apelação criminal. Tráfico privilegiado. Insurgência das partes. Recurso da defesa pela desclassificação para o art. 28 da LA. Não cabimento. Pleito ministerial pela exasperação da pena-base diante da natureza da droga apreendida. Não acolhido. Inobstante a lesividade das substâncias apreendidas, a quantidade reduzida não reclama tal exasperação. Pedido pelo afastamento do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Possibilidade. Conquanto o réu seja tecnicamente primário e não tenha antecedentes criminais, observa-se que ostenta passagem pela Vara da Infância e Juventude por prática de atos infracionais equivalentes ao tráfico de drogas (tendo inclusive cumprido medidas socioeducativas). Redutor afastado. Penas readequadas, o que torna inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Fixação de regime inicial semiaberto. Recurso defensivo não provido e apelo ministerial parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Criminal 1501137-72.2021.8.26.0594; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Lençóis Paulista - 2ª Vara; Data do Julgamento: 03/11/2022; Data de Registro: 03/11/2022);

“Apelação. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento de ensino. Art. 33, caput, c.c. art. 40, III, da Lei nº 11.343/06. Pleito pela desclassificação da conduta para o art. 37 da Lei Antidrogas. Não acolhido. Restou comprovado, no caso em tela, a contribuição estável e permanente, e o envolvimento direto, do réu com o tráfico. Pedido de aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Impossibilidade. Antecedentes infracionais que indicam que o apelante se dedica a atividade criminosa, vedando-lhe o reconhecimento do benefício. Pleito pelo afastamento da causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06. Acolhido. Crime praticado no período noturno e durante o fechamento de estabelecimentos de ensino em virtude da pandemia da Covid-19. Bem jurídico tutelado pelo inciso em questão que não sofreu riscos no caso em tela. Reprimenda final fixada no mínimo legal. Pedido de afastamento e reconhecimento da inconstitucionalidade da pena de multa. Não acolhido. Reprimenda pecuniária compõe a pena principal, não sendo facultado ao magistrado perdoá-la. Constitucionalidade da pena de multa reconhecida e pacificada na jurisprudência dos tribunais superiores. Pleito de reconhecimento do período em que réu esteve em prisão preventiva para fins de detração penal. Impossibilidade. Requisitos da detração a serem analisados pelo Juízo das Execuções Criminais. Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Criminal 1500281-06.2021.8.26.0628; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapevi - Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/12/2022; Data de Registro: 02/12/2022).

Destarte, torno definitivo o quantum da pena fixado acima.

Inviável a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direito (artigo 44 do Código Penal) ou a concessão da suspensão condicional da pena (artigo 77 do Código Penal), vez que a quantidade de pena aplicada não autoriza a concessão desses benefícios.

Considerando as circunstâncias do crime em comento, de extrema gravidade, a

quantidade e natureza das drogas apreendidas (cocaína e maconha), a primeira de maior poder de dependência e de maior risco à saúde, bem como a prática do crime logo após deixar a Fundação Casa onde cumpria medida socioeducativa de internação por tráfico, a evidenciar a reiteração delitiva, outro regime que não o mais gravoso será ineficaz para iniciar o processo de ressocialização do acusado. Destarte, fixa-se o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena.

Cabe invocar ensinamento do Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06). QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE PROVAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS. REGIME FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 E ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PATAMAR DA REPRIMENDA SUPERIOR A 4 ANOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 4. A quantidade e/ou natureza de drogas apreendidas constitui elemento idôneo para justificar a imposição de regime mais gravoso, de acordo com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas e no art. 33, § 3º, do Código Penal - CP e em consonância com o entendimento desta Corte. (...) Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 414347 / SP 2017/0219134-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (1183), Data do Julgamento: 08/02/2018, Data da Publicação: 21/02/2018, T5 - QUINTA TURMA).

E, o teor do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal não pode ser considerado como alteração de regime inicial a partir de pena cumprida, funcionando como progressão indireta. Isto porque incabível análise de progressão, vez que não é possível saber em sede de processo de conhecimento se o acusado está preso por este ou outro processo, qual o mérito do réu, e se houve algum incidente durante a sua prisão que altera o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo necessários ao reconhecimento do benefício. No mais, a competência originária para a análise de eventual progressão de regime é da Vara das Execuções Criminais (artigo 66, III, "b", da Lei n. 7.210).

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO MINISTERIAL VISANDO A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO - ACOLHIMENTO Sendo o réu reincidente, adequada a fixação de regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. Detração do tempo de prisão cautelar que há de ser examinada pelo Juízo das Execuções - Recurso provido." (TJSP, Apelação 0026588-11.2011.8.26.0050, Relator(a): Luis Augusto de Sampaio Arruda, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 10/03/2014, g.n.)";

"(...) Pena. Crime comum praticado mediante violência ou grave ameaça. Roubo circunstanciado. Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena. Entendimento. Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas nos incisos do § 2º do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação. Pena. Cumprimento de prisão cautelar por lapso temporal suficiente à progressão de regime. Impossibilidade de influência na fixação do regime inicial para cumprimento de pena. Entendimento. Em que pese o teor do art. 387, §2º, do CPP, a análise de pedido de fixação de regime mais brando, em razão de cumprimento de pena cautelar ou definitiva, não pode ser efetuada pelo Juízo de conhecimento, pois se confunde com um pedido de progressão de regime, a ser apreciado pelo Juízo da Execução, que é o natural para avaliar o

preenchimento dos requisitos subjetivos e objetivos para sua concessão." (TJSP, Apelação 0020392-25.2012.8.26.0071, Relator(a): Grassi Neto, 7ª Câmara de Direito Criminal, j. 24/10/2013, g.n.);

"HOMICÍDIO - pena - base fixada no mínimo legal e reduzida corretamente na metade em razão do iter criminis percorrido. REGIME INICIAL - detração - consideração do tempo de prisão processual para fixação do regime inicial - art. 387, §2º, do CPP - impossibilidade de entender-se o dispositivo legal como progressão antecipada, visto ser inviável a análise dada a falta de elementos a respeito do cumprimento da prisão cautelar, devendo a questão ser melhor analisada em execução - impossibilidade da progressão indireta - dispositivo legal que na verdade prevê desconto de pena processual da pena imposta para fins do art. 33, §2º, do CP - caso em tela em que o regime foi fixado com base no art. 33, §3º, do CP, onde não se leva em conta o quantum de pena imposta - improvimento." (TJSP, Apelação 0016797-87.2012.8.26.0048, Relator(a): Lauro Mens de Mello, 8ª Câmara de Direito Criminal, j. 07/05/2015, g.n.).

Assim, eventual pedido de progressão de regime prisional há que ser deduzido ao Juízo das Execuções, que poderá aferir o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para tanto.

III. Dispositivo.

Ante o exposto e do mais que consta dos autos, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu GABRIEL FERNANDO PEREIRA APARECIDO, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão (regime inicial fechado) e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em seu valor mínimo unitário, como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06.

Condeno o acusado ao pagamento de custas processuais no valor de 100 (cem) UFESPs. nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, ficando suspensa a execução por ser o acusado beneficiário da Justiça Gratuita.

O réu respondeu preso ao processo e assim deverá permanecer, mormente porque se concluiu por sua responsabilização criminal. Portanto, tratando-se de crime grave, não poderá recorrer em liberdade. Em casos tais, se posicionou o Superior Tribunal de Justiça: "Não se reconhece o direito ao apelo em liberdade a réu que permaneceu preso desde o flagrante e durante toda a instrução do processo. A manutenção da prisão constitui-se em um dos efeitos da respectiva condenação. Precedentes. Ordem denegada" (HC 36474/SP-HABEASCORPUS-2004/0091136-3. Relator Ministro GILSON DIPP (1111). Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 14/12/2001. Data da Publicação/Fonte: DJ 21.02.2005 p.198). No mais, sua conduta indica ousadia e periculosidade, praticando crime que tem causado a degradação do indivíduo e da sociedade brasileira, de modo que a custódia cautelar se mostra necessária para assegurar a ordem pública e para a aplicação da lei penal, especialmente considerando o contexto de desemprego e a prática do crime logo após deixar a Fundação Casa, onde cumpria medida socioeducativa de internação por tráfico. Logo, em atenção ao disposto no § único, do artigo 316, do Código de Processo Penal, mantenho a prisão cautelar do réu.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido e extraia-se guia de execução provisória, em caso de recurso.

Determino a incineração da droga apreendida, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06.

Não provada a origem lícita da quantia e telefone apreendidos, decreto sua perda em favor da União, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Dado o uso para a prática ilícita, decreto o perdimento da balança apreendida em favor da União e, não havendo interesse na sua conservação, determino a destruição, nos termos do artigo 124 do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral.

P.I.C.

Jardinópolis, 19 de dezembro de 2022.

Joice Sofiati Salgado
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA